



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים:
1. נציגות הבית המשותף רחוב מרחביה 14 תל אביב
 2. דן ללז
 3. אמנון קשי
 4. הינדה ווייס
- ע"י ב"כ עוה"ד צבי קורין
מרחוב קפלן 2, בית יכין, תל אביב

נ ג ד

- הנתבעות:
1. רחל טמיר
 - ע"י ב"כ עוה"ד ענת מאירי
 - ממרכז רננים ת.ד. 11439 מכבים
 2. רות לביא
 - ע"י ב"כ עוה"ד יוסף מילר
 - מרחוב פרוג 8 תל אביב

פסק דין

תובענה זו עניינה בבית המשותף ברחוב מרחביה 14 תל אביב הבנוי על חלקה 34 בגוש 8986 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובעת 1 הינה נציגות הבית.
התובעים 2 עד 4 הינם בעלים של 5 דירות בבית (תתי חלקות 8 עד 12).
הנתבעת 1 הינה בעלים של דירות בבית (תתי חלקות 3, 7 ו-13).
הנתבעת 2 הינה דיירת מוגנת בדירה הידועה כתת חלקה 13 (להלן: "דירת הנתבעות").

התביעה הוגשה כנגד נתבעים נוספים, בעלים של דירות אחרות בבית, אך הדיון בה פוצל בהתאם להחלטתי מיום 12.01.12.

התובעים טוענים כי הנתבעת 2, ביחד עם אחרים, ביצעה בניה על הגג, לרבות, שער המונע גישה לגג. הנתבעות הרחיבו את דירת הנתבעות לשטח הגג בניגוד להסכם השכירות ותוך פלישה לרכוש המשותף, הנתבעת 2 משתמשת בגג הבית כמרפסת לדירתה ומונעת גישה לגג. הנתבעות הרסו מרצפות מקוריות ברצפת חדר המדרגות והעבירו צינור ביוב ברכוש המשותף אשר גרם גם לנזקים לרכוש המשותף. הנתבעת 1 פלשה לשטח משותף מתחת לגרם המדרגות ויצרה בו מחסן אשר השימוש בו גם מפריע לבעלי הדירות. בנוסף נותרו הנתבעות חבות מיסי נציגות בגין דירת הנתבעות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור התבקשו סעדים כלהלן – הריסת כל תוספת בניה, מחסן ושער ברכוש המשותף, צו המורה על מתן זכות גישה ומעבר לגג הבית, חיוב בתשלום מיסי נציגות, חיוב בתשלום העתקת צינור הביוב ותיקון הרצפות, תשלום עבור איטום הגג ותשלום דמי שימוש ראויים.

התובעים זנחו חלק מן הסעדים המבוקשים במהלך ניהול ההליכים וסיכומיהם והתמקדו בשלושה – פלישת הנתבעות לגג המשותף על ידי תיחומו, הקמת קירות וסיפוחו לדירת הנתבעות, פלישת הנתבעת 1 למחסן – חלל מתחת לגרם המדרגות בקומת הכניסה, ותשלום דמי שכירות ראויים בגין שני השימושים האמורים (ר' סעיף 6 לסיכומי התובעים). משכך נתייחס בפסק דין זה רק לסעדים הרלבנטים האמורים.

הנתבעת 1 טענה כי המחסן מתחת לגרם המדרגות מסומן בתוכניות בניה מעת הקמת הבית ובסמוך לכך. אומנם, זה לא נרשם כיחידה נפרדת או כהצמדה בעת רישום הבית המשותף. אולם, המחסן היה במקום כל העת בשימוש משפחת הנתבעת 1, מקימי הבית ובעליו מאז הקמתו, ונתקבל בידה בירושה. במחסן גם נעשה שימוש כל השנים על ידי הנתבעת 1 וקודמיה בזכויות ועל ידי שוכרים מטעמם, לכל הפחות מאז שנת 1963 ומשכך התביעה גם התיישנה. מוכחשת הטענה כאילו השימוש במחסן גורם למטרד כלשהו. הנתבעת 1 טוענת כי היא איננה מונעת כל גישה לגג הבית וכי דירת הנתבעות הורחבה כדין לפני שנת 1985 בהסכמת כל בעלי הזכויות והיא הושכרה, כפי שהיא, לנתבעת 2. התביעה לתשלום דמי שימוש הוכחשה.

הנתבעת 2 טענה כי התביעה כנגדה בגין השימוש בגג התיישנה, שהרי שימוש זה מבוצע על ידיה מאז שנת 1985. הנתבעת 2 הכחישה כי גרמה לנזק לרכוש המשותף או כי פלשה לרכוש המשותף. לטענתה, כל שינוי שבוצע, בוצע לפני כניסתה לדירה וממילא היתה גם הסכמה של כל בעלי הזכויות בבית, שהרי במועדים הרלבנטיים היתה המנוחה מלכה רוזין הבעלים של הבית בשלמות. הנתבעת 2 טענה עוד כי היא איננה מונעת גישה או שימוש בגג ואין לחייבה בתשלום דמי שימוש.

אציין כי לבקשת הנתבעת 1 ניתנה לה אורכה להגשת סיכומים מטעמה עד ליום 30.04.13. דא עקא, עד למועד כתיבת שורות אלו לא הוגשו סיכומים מטעמה. משכך, גם בהתאם להחלטתי מיום 08.04.13 וגם משהמתנתי עם מתן פסק הדין זמן נוסף לאחר המועד שנקבע לבקשת הנתבעת 1 להגשת סיכומים מטעמה כאמור, הועבר התיק למתן פסק דין ללא סיכום הטענות מטעם הנתבעת 1.

לשם נוחות ופשטות הדיון נתייחס בנפרד לכל אחד מרכיבי התביעה שנותרו להכרעתי.

דיון

המחסן מתחת לגרם המדרגות

הכלל הבסיסי הוא כי נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של התובע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי תשריט הבית המשותף, ועל כך אין מחלוקת, המחסן מתחת לגרם המדרגות בקומת הקרקע (להלן: "המחסן") אינו רשום כיחידה נפרד בבית ואינו צמוד לאיזה מיחידות הבית. די בכך מבחינת התובעים כדי לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש, בפרט כאשר המדובר בהליך המתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פ"ד לח (4) 487). עתה עובר נטל ההוכחה לידי הנתבעת 1 כי בידה זכויות הקניין במחסן או כי בידה הסכמות של בעלי הדירות לשימוש בו (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)).

משלא הגישה הנתבעת 1 סיכומים מטעמה כאמור לעיל, הרי ששילוב הוראות תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") עם תקנה 157(2) לתקנות, ובפרט בנסיבות בהן התביעה מתבססת על מסמכי רישום הבית המשותף כאמור, מצדיק קבלת התביעה ומתן הסעד המבוקש בהקשר זה.

אולם, גם בחינת הראיות והדין לגופם של דברים מצדיקה את קבלת התביעה בהקשר זה.

תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, בדומה להצמדה של רכוש משותף לדירה על פי סעיף 62 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), טעונה הסכמה של בעלי הדירות. בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף כפי שנפסק בע"א 2525/92 גבי וקרני דאוכברגר נ' עיריית רמת גן פ"ד מז(5) 850: "...משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם...' (ר' גם רע"א 698/85 בן צור נ' נעים ששון מא(3) 144; י. ויסמן דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז, 1997) עמ' 455-454).

ברי כי שימוש ייחודי במחסן (שאינו מחלוקת שהיה נעול לאורך השנים ובשימוש מטעם הנתבעת 1 בלבד) לא יכול להיות, מעצם טבעו, בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף, דורש אם כן הסכמה של כל יתר בעלי הדירות - ומהי אותה הסכמה נדרשת?

כבר נפסק בעבר כי הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קנייניות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללל ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא (3) 210).

על מנת להסיק ויתור מהתנהגות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)).

משעה שניתנה ההסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לז (2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ (2) 388).

ובמקרה דנן לא עלה בידי הנתבעת 1 הסכמה קניינית לבעלות במחסן וגם לא הסכמה לשימוש ייחודי.

ראשית, לא עלה בידי הנתבעת 1 להוכיח כי בידה זכויות קנייניות במחסן. בהקשר זה לא הובאה ולו ראיה אחת מפורשת אחת לקיומה של הסכמה לבעלות קניינית של הנתבעת 1 במחסן.

ויוער, מן הביקור במקום עולה כי המדובר בתא נפרד מתוחם בקירות, דלת וחלון. לא היתה כל מניעה בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק") וגם לא על פי חוק בתים משותפים, תשי"ג – 1952 אשר קדם לו, לרשום את המחסן כיחידה נפרדת בבית המשותף, אף אם המדובר בשטח קטן יחסית. ברי כי גם לא היתה כל מניעה לרשום את המחסן האמור כהצמדה לאחת מדירות הבית. אף על פי כן, אין בידי הנתבעת 1 כל הסבר מניח את הדעת מדוע הדברים לא נעשו, בפרט כאשר היה בעלים אחד בבית בעת רישום הבית המשותף.

וידוגש, הנתבעת 1 איננה טוענת כי יחידה זו אמורה להיות צמודה לדירה זו או אחרת בבית. למעשה, טענת הנתבעת 1 היא כי המדובר ביחידה נפרדת ועצמאית. דא עקא, בבית משותף ישנה "דירה" וישנו "רכוש משותף" (סעיף 52 לחוק). משנרשם הבית כבית משותף, ולא הוגדר בו המחסן כיחידה נפרדת או כהצמדה לאיזה מדירות הבית, לא יכולה להיות בו בעלות נפרדת.

שנית, מעדויות הנתבעת עולה כי הזכויות בכל דירות הבית היו, לאורך השנים, בידי בני משפחתה (ראה סעיף 2 לתצהירה). אף על פי כן, צו רישום הבית המשותף לא תוקן מעולם כך שישקף גם את המחסן שנבנה, לכאורה עוד בהקמת הבית, ויקנה זכויות קנייניות במחסן זה. תיקון צו הרישום כאמור לא בוצע גם כאשר חולקו דירות הבית בין יורשי הבעלים המקוריים באופן זה שלא היה עוד בעלים אחד משותף לכל הדירות בבית.

ואעיר, הסבריה של הנתבעת 1 מדוע לא נרשם המחסן במסגרת רישום הבית המשותף אינם משכנעים (ר' עדותה בעמוד 22 שורות 18-7). אף אם המדובר היה באנשים "קשי יום", אף אם היה מדובר באנשים שהיו בעלים של כל הבניין ופעלו בו כרצונם, הרי שבסופו של דבר מדובר בבעלים אשר היו מודעים למשמעות הרישום ואף הסדירו את רישום הבית המשותף כבר לפני כ- 60 שנים! לכאורה, לפי "הסבריי" הנתבעת, הרי שגם רישום זה היה "מיותר" מבחינתם, אך למרות זאת הוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נעשה. ואדגיש, אף אם הדברים האמורים נכונים לתקופה שבה היה בעלים אחד לכל הדירות בבית, הרי שהדברים ודאי לא היו נכונים כאשר החלה הבעלות מחולקת בין קרובי משפחה שונים ומועברת לצדדים שלישיים.

שלישית, חלק מדירות הבית נותרו גם כיום בבעלות היורשים המקוריים. דא עקא, על אף שהמדובר בקרובי משפחה של הנתבעת 1, על אף שהם יורשי הזכויות המקוריים, ועל אף שלכאורה בידם לאשר את ההסכמות שניתנו לנתבעת 1 לשימוש במחסן או אפילו לזכות קניינית בו, לא הובאה על ידי הנתבעת 1 ולו עדות אחת מבעלי הזכויות האלו לתמיכה בטענותיה. לא ברור מדוע לא הובאו לעדות ה"ה אלגזי או הגב' פרנס, שאף נתבעו בהליך המקורי (בטרם הורתי על פיצול הדיון).

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

בנסיבות דנן ניתן להסיק כי הסכמה לשימוש במחסן ובודאי הסכמה קניינית להצמדתו, לא ניתנה על ידי בעלי הדירות האחרים.

רביעית, העובדה כי המחסן מופיע בהיתרי בניה משנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת (נספחים לתצהיר הנתבעת 1) מלמדת אך על מצבו התכנוני של המחסן ואולי גם על קיומו הפיזי. דא עקא, אין בהיתרי הבניה כדי ללמד דבר בנוגע לזכויות הקנייניות בו. דווקא היתרי הבניה האמורים מחזקים את המסקנה כי בכוונת מכוון לא נרשם המחסן כיחידה נפרדת או כהצמדה לאחת מיחידות הבית. מהיתרי הבניה אנו למדים כי המחסן היה קיים ומאושר תכנונית בעת רישום הבית המשותף (למעלה מ-20 שנה אחרי מתן ההיתרים האמורים). עוד אנו למדים כי היתה גישה ישירה למחסן מהחנות הסמוכה. אף על פי כן, כאשר באו בעלי הזכויות בבית לרשום את הבית המשותף, ויוזכר, המדובר באותה עת בבעלות אחת בכל היחידות בבית, על אף שהיה תא מתחת לחדר המדרגות, על אף שככל הנראה נעשה בו שימוש, על אף שהיה פתח בהיתר מהחנות הסמוכה למחסן האמור, בחרו הבעלים שלא לרשום את המחסן, לא כהצמדה לחנות, לא כהצמדה לאיזה מדירות הבית ולא כתא נפרד. המסקנה המתבקשת כי במודע בחרו להותיר את המחסן כחלק מן הרכוש המשותף.

חמישית, לא עלה בידי הנתבעת 1 להוכיח כי נתקבלו הסכמות פוזיטיביות של בעלי הדירות בבית לשימוש המבוצע על ידה במחסן. בהקשר זה לא הובאה ולו ראייה אחת, המלמדת על קבלת הסכמה כלשהי של מי מבעלי הדירות בבית - לא הסכמה בעל פה וודאי שלא הסכמה בכתב. בהקשר זה מעיד מר לוטן - "המחסן הוזכר במהלך ישיבות הוועד לא היה טיפול באופן ישיר לנסות לפנות אותה משם. אני אמרתי שזה חלק מהרכוש המשותף. רחל ענתה שהעבירו לה את זה המשפחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שהיא היורשת של המחסן ששנים זה שלה. שאלתי אם יש לה ניירת והיא אמרה לי שלא" (עמוד 8 שורות 8-10) כך גם מר קשי (עמוד 15 שורה 6).

לא ניתן לקבל את טענת הנתבעת 1 כי התביעה התיישנה, שהרי הסגת גבול הינה מסוג "עוולה מתמשכת" שבכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום (ר' ע.א. 35/71 חב' ישראל אוטורליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם וכן טדסקי, אנגלרד, ברק וחשין: דיני הנויקין, תורת הנויקין הכללית, מהד' שניה תשל"ז, בעמ' 724 ה"ש 7). ויודגש, אנו עוסקים כאן בתביעה שעניינה הסגת גבול בלבד וכל הכרעה בנוגע לזכויות קנייניות הינה אינצידנטלית בלבד.

בנסיבות דנן כל שיש בידי הנתבעת 1 להוכיח הוא העדר התנגדות של בעלי דירות לשימוש במחסן לאורך שנים – כך עולה מעדותו של מר לוטן, בעלים של דירה בבית משנת 2000 – "המחסן מתחת למדרגות לא שימוש אותי מעולם. הוא שימש בעלי חנויות בבניין. ש.ת. תמיד היו בעלי עסק שהשתמשו במחסן זה לא היה עסק עצמאי. ש.ת. משנת 2000 נכנסים למחסן ויוצאים ממנו בעלי החנויות שמחזיקים בו. ש.ת. אני זוכר בעלי חנויות כי זה מאוד הפריע. ש.ת. לא תמיד ראיתי מי נכנס אבל תמיד היו שם סחורות לא עקבתי בדיוק מי נכנס. ש.ת. המחסן שימש את בעל הקיוסק הפינתי בארבע חמש שנים האחרונות" (עמוד 7 שורות 14-19). הוא גם לא "התלונן" בפני קודמתה של הנתבעת 1 בזכויות בנוגע לשימוש במחסן – "אני זוכר את אימה של גברת טמיר ומעולם לא דיברתי איתה על המחסן" (עמוד 8 שורה 11). כך עולה מעדותו של מר קשי (עמוד 12 שורה 14 ואילך ובהמשך בעמוד 14 שורות 27-30). לא הובאה על ידי התובעים כל ראיה כאילו היו התנגדויות אחרות לשימוש עוד לפני רכישת הזכויות על ידי מר לוטן ולכאורה ניתן להניח שאכן גם לא היתה התנגדות שכזו מצידם של בעלי הזכויות הקודמים והאחרים, בני משפחתה של הנתבעת 1.

דא עקא, אי התנגדות של שכנים לשימוש, אף אם זו נעשתה לאורך שנים, אין בה די כדי להוות הסכמה מודעת לשימוש. לכל היותר ניתן להסיק משתיקה שכזו הסכמה מכללא המקימה רשות שימוש הדירה, זכויות אישית, אשר ניתנת להפסקה בכל עת על ידי המעניק אותה, בודאי כאשר המדובר ברשות שימוש ללא תמורה – "רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חנינם המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני" (פרופ' נ. זלצמן רשיון במקרקעין, הפרקליט מב 24, 57; וראה גם מ. דויטש, קניין כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

משהוגשה התובענה דנן הביעו בברור חלק מבעלי הדירות את רצונם להפסקת השימוש על ידי הנתבע (מיגל דויטש קניין (תשנ"ט, כרך ב') עמ' 414, רע"א 6339/97 רוקר ואח' נ' סלומון ואח' פד"י נח (1) 199 וע"א (ת"א) 2816/03 ציפורה קונצ'צקי ואח' נ. דליה שפילן ואח' תק-מח 2006 (2), 991). ויודגש, רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם בהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח כי רשות השימוש שניתנה לה, מכח שתיקת בעלי הדירות, הינה רשות שימוש בלתי הדירה.

ראשית, יש לזכור כי המדובר במקרה דנן ברשות שימוש הנלמדת מכלל, ללא הסכמה פוזיטיבית. הסכמה מכללית שכזו, מעצם טבעה, איננה יכולה לקבל תוקף קנייני וגם לא קונקרטי, תמורה וצפייה לגיטימית לשם קבלת תוקף בלתי הדיר.

שנית, לא הוכח כי הנתבעת ביצעה השקעות או הוציאה כספים כלשהם במחסן. אין מחלוקת כי במסגרת עבודות שיפוץ הבית ביצעה התובעת 1 דווקא עבודות לחיזוק המדרגות וכפועל יוצא של תקרת המחסן.

שלישית, לא הוכחה כל תמורה לבעלי הדירות בגין השימוש במחסן. למעשה, כלל לא נטען כי ניתנה תמורה בהקשר זה אלא אך כי המדובר היה בזכות בירושה. ויודגש, גם בהקשר זה לא הובאה על ידי הנתבעת 1 כל עדות של בני המשפחה, בעלי הזכויות הנוספים בבית מכוח אותו עיזבון יסודי.

רביעית, לא הוכחה צפייה לגיטימית של הנתבעת 1 לכך שתוכל לעשות שימוש לצמיתות במחסן ללא כל תמורה, בוודאי לצורך מתן רשות שימוש לצד שלישי. ויודגש, מעת תחילת ביצוע עבודות השיפוץ גם נשללה מהנתבעת רשות השימוש במחסן בפועל כשזה נדרש לטובת שיפוץ הבית (עמוד 23 שורות 4-6) ואף על פי כן היא לא נקטה בכל הליך למימוש זכויותיה לכאורה. יש גם להוסיף בהקשר זה כי על פי העדויות מטעם הנתבעת הרי שהשימוש במחסן ניתן לשוכר מטעמה בגדר הטבה ללא תשלום וללא כל צפייה להמשך השימוש בו (עמוד 22 שורה 27 עד עמוד 23 שורה 1).

בנסיבות אלו, כאמור, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי בידה כיום עוד זכות כלשהי במחסן ויש מקום להיעתר לתביעה למתן צו עשה לסילוק ידה של הנתבעת 1 מן המחסן.

אולם, התנהלות התובעים 2-4 ושתיקתם לאורך השנים, לרבות קודמיהם בזכויות (כפי שאוזכרו וצוטטו לעיל), הקנו לנתבעת כאמור רשות שימוש הדירה מכללית במחסן.

הדברים מתחזקים לאור עדויותיהם של מר רפאל צדיק (ר' עמוד 32 שורות 24-29) ומר אברהם מלכה (עמוד 30 ואילך) בדבר השימוש שבוצע במחסן במשך שנים מטעמה של הנתבעת 1.

לאור רשות השימוש מכללית כאמור מוצא אני לנכון לדחות את התביעה לחיוב הנתבעת 1 בתשלום דמי שימוש ראויים.

ראשית, לא עלה בידי התובעים להוכיח נזק ממון ישיר המזכה בפיצוי בגין הסגת גבול בהתאם להוראות סעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. בהקשר זה לא הוכח כל הפסד ממון של מי מהתובעים בשל השימוש במחסן, בפרט כאשר הוכח כי מאז שנת 2005 גם לא מתקבלת כל תמורה בגין השימוש במחסן (עמוד 30 שורות 28-30).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, עצם ההכרה ברשות שימוש מכלל לא תמורה שניתנה לנתבעת על ידי התובעים 2-4, שוללת את זכותם לקבלת דמי שימוש בגין התקופה הנדונה.

שלישית, גם אין בידי לקבל את חישובי התובעים בהקשר זה - הוכח בפני, כפי שאוזכר לעיל, הן מעדות הנתבעת 1 והן מעדות השוכר - אברהם מלכה, כי בפועל לא שולמו דמי שכירות בגין המחסן ואפילו לא ניתן היה להשכירו (עמוד 22 שורות 28-29). דמי שימוש ראויים בפועל בהקשר זה עומדים בשיעור אפס, בודאי בהתייחס לשנים האחרונות. כהערת אגה אעיר כי השמאי הראל לא הביא בחשבון את העובדה כי המדובר במחסן קטן במיוחד עם אפשרויות שימוש מוגבלות ביותר, שעה שעסקאות ההשוואה עליהן הסתמך מתייחסות למחסנים הגדולים מספר פעמים מהמחסן דנן.

הרחבת דירה בקומת הגג

מן הביקור במקום עולה כי הבניה בגג אליה מתייחסים התובעים בהליך דנן הינה, למעשה, הרחבה לדירת הנתבעות (ר' פרוטוקול ביקור במקום עמוד 1 שורות 27-30).

הוכח בפני כי תוספת הבניה האמורה בוצעה בשנת 1984, עוד לפני שהנתבעת 1 ירשה את הזכויות בדירה ועוד בטרם הנתבעת 2 רכשה את הדיירות המוגנת בדירה. כך עולה מעדותה של הנתבעת 1 (עמוד 21 שורה 24 ובהמשך עמוד 23 שורה 29 עד עמוד 24 שורה 2). כך עולה גם מעדותה של הנתבעת 2 - "מתחילת 1985 הפכתי להיות דיירת מוגנת בדירה למעלה. ש.ת. אני לא מכירה את שוכרת הדירה הקודמת שהייתה לפניי אני מכירה רק את רוזין מלכה ואת הגברת רחל טמיר. ש.ת. לא ראיתי את שוכרת הדירה. ש.ת. פעם ראשונה שבאתי לראות את הדירה היא הייתה פנויה לחלוטין. ש.ת. מצב הדירה היה רעוע, הרוס, חורבה אין חלונות אין דלתות. ש.ת. אני לא עשיתי שום שינוי בקירות החיצוניים של הדירה. ש.ת. כל מה שהיה פיזי במקום ככה קיבלתי אותו" (עמוד 27 שורה 28 עד עמוד 28 שורה 4).

גם התובעים אינם יודעים, למעשה, מתי נבנתה התוספת, ובודאי שלא על ידי מי. כך עולה מעדותו של מר לוטן - "שאני עברתי לבית הדירה למעלה כבר הייתה מורחבת אני הייתי מודע לזה ואני יודע שהיא הורחבה קודם. ש.ת. בנושא ההרחבה לא אמרתי כלום לגברת טמיר ולא לאימה. הדברים הוזכרו בפגישות מאוחרות יותר אך בהתחלה לא דיברנו על זה קודם התמקמתי בבניין לא הייתי בעניין לטפל בחריגות בנייה ובעניינים מהסוג הזה" (עמוד 18 שורות 14-18 ובהמשך גם בעמוד 9 שורות 9-12) וכך מעדותו של מר קשי - "לא ראיתי את גברת שוש לביא בונה על הגג. ש.ת. אני יודע מתי נבנתה תוספת לדירה של גברת לביא" (עמוד 15 שורות 28-30 ובהמשך עמוד 16 שורות 8-11).

לכל זאת יש להוסיף את חוות דעתו של מר שלמה בן יוסף ופיענוח תצלומי האוויר שצורפו על ידו, שלא נסתרו, וכפי שהוא מעיד - "בשנת 1984 בוצעה שם בנייה קשיחה. בוצעו שינויים בקיר החיצוני כמו שראיתי שפתחו בהם פתחים כן המשכתי לדגום את המקום כדי להגיד שמאז לא בוצע דבר משנת 1984 ועד היום בדגימות של אחת לעשור" (עמוד 18 שורות 11-13).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור העדויות שהוצגו בפני ניתן גם לדחות את טענת התובעים כאילו ההרחבה היתה עילת הסכסוך שבין הנתבעות דנן בהליך פינוי שהתנהל בניהן. מקובלות עלי עדויות הנתבעות כי הסכסוך פרץ בשל מחלוקות אחרות ובניה בתוך הדירה פנימה (עמוד 20 שורות 25-30 וראה גם סעיפים 2 ו-8 למוצג נ/1).

אף שאין מחלוקת כי אין בידי הנתבעות הסכמות בכתב להרחבה מקובלת עלי עדות הנתבעת 1 בדבר ההסכמות שניתנו על ידי כל בעלי הדירות במועד ביצוע ההרחבה - "הבניין הזה התנהל כעסק משפחתי שהיה אחד בישביל השני גם כאן כשאימא שלי הגישה לעירייה יכול מאוד להיות שביקשו ממנה והיא כן נתנה. לאימא שלי היה ייפוי כוח מכולם יש לי עדיין את ייפוי הכוח הזה. הכול היה יד אחת. ש.ת אימא שלי קיבלה את ההסכמה מהאחיות שלה. היא הסכימה להרחבה כי היא פנתה לעירייה עובדה שהיא השכירה את הדירה הזו 2.55 חדרים לרות לביא. ש.ת יש לי ייפוי כוח מאחת לשנייה" (עמוד 21 שורות 25-30). במיוחד אמורים הדברים כאשר עסקינן בהרחבת דירה שבוצעה לפני כ- 30 שנה.

כאמור, הבית המשותף נרשם בשנת 1955, כ- 30 שנה לפני ביצוע הרחבת הבניה כאמור. משכך, ברי כי צו הרישום אינו משקף את גודלה של הדירה לאחר ההרחבה. הפרקטיקה הידועה היא כי לא תמיד מתוקן צו הרישום כאשר מבוצעת הרחבה בדירה קונקרטיית ואף על פי כן הזכויות הקנייניות בדירה כוללות גם את הרחבתה המאוחרת, אף אם זו לא נרשמה בצו תיקון.

במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בתובעים אשר רכשו את זכויותיהם שעה שדירת הנתבעות כבר הורחבה שנים רבות קודם לכן, ואין הם יכולים להתנער מהרחבה שבוצעה בהסכמה בעבר, אף אם זו טרם נרשמה בצו תיקון.

ויוודגש, מטעם הנתבעים העיד מר לוטן שהיה בעל דירה בבית עוד משנת 2000 (ומכר את זכויותיו לתובעת 4 בשנת 2011) והוא רכש זכויותיו שעה שההרחבה כבר היתה בנויה. הוא גם מעיד כי הוא היה מודע לקיומה של ההרחבה ואף על פי כן, לא פנה או נקט בכל פעולה בנוגע אליה במשך כל תקופת בעלותו (ר' עמוד 7 שורה 6 ועמוד 8 שורות 14-18). כך גם עולה מעדותו של התובע 3 לתקופה שמאז 2005 (עמוד 14 שורות 20-21). התנגדות התובעים עתה להרחבה האמורה יש בה משום עמידה על זכות קניינית בחוסר תום לב וממילא מתקיימת בנסיבות אלו מניעות מטעמי צדק (ר' ע"א (מחוזי - חיפה) 1677/05 נאווה כרמל נ' ראול ינקוביץקי (פורסם בנבו) אשר אושר בבית המשפט העליון ברע"א 8186/07 נאווה כרמל נ' ראול ינקוביץקי (פורסם בנבו); לעקרון תום הלב החולש גם על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף ר' בע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454, ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז (4) 737 ורע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פד"י נח (1) 199; לעקרון מניעות מטעמי צדק ר' הלכות שאוזכרו לעיל).

ויוודגש, השאלה אם קיים היתר בניה להרחבה אין בה כדי להשפיע על ההחלטה נשוא ההליך דנן. כשם שקיומו של היתר בניה אינו מבסס זכויות קנייניות כך גם העדרו של היתר בניה אינו יכול לשלול זכות קניינית או הסכמה שניתנה לבעל דירה להרחיב את דירתו. בהליך דנן עסקינן בזכויות קנייניות ותו לא. דיני התכנון והבניה מסורים להכרעתן של רשויות וערכאות אחרות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 22/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור אין בידי אלא לדחות את התביעה להריסת הרחבת דירת הנתבעות.

כפועל יוצא ברי כי יש מקום לדחות גם את התביעה לתשלום דמי שימוש ראויים בהקשר זה.

בכתב התביעה העלו התובעים טענות בדבר השתלטות של הנתבעות גם על חלקים נוספים בגג. אומנם, בסיכומיהם זנחו טענות אלו והתמקדו אך בבניה על הגג כאמור לעיל, בין היתר לאור העובדה כי המחסן שהתוקן על הגג על ידי הנתבעת 2 הוסר (עמוד 27 שורה 7) וכך גם יריעת הברזנט והסככות בחזית הגג (עמוד 23 שורות 13-14 ועמוד 30 שורות 13-14). אולם, למען הסר ספק ומניעת מחלוקות נוספות בעתיד יש מקום להבהיר כי, למעט הרחבת הדירה כאמור, כל שטח הגג שנותר הינו רכוש משותף אשר לא ניתן למנוע גישת מי מבעלי הדירות אליו בכל דרך, כפי שקיימת כיום (עמוד 17 שורות 8-9), לרבות הצבת שער, גדר או אף מיטלטלין, וזאת למרות שיש בגג זה לשמש גם כדרך הגישה לדירת הנתבעות. ברי כי גם כל בינוי בשטח הגג מחייב הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות ואין הנתבעות או מי מהן רשאיות לבצע כל בינוי בגג ללא קבלת הסכמה כאמור.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה לצו עשה ומורה לנתבעת 1 לסלק את ידה מן המחסן ולסלק ממנו כל ציוד השייך לה או למי מטעמה. ויודגש, נאסר בזה על הנתבעת 1 לסגור במנעול את המחסן האמור או לעשות בו כל שימוש יחודי.

אני דוחה את התביעה לתשלום דמי שימוש בגין השימוש במחסן.

אני דוחה את התביעה בכל הקשור להרחבת דירת הנתבעות לגג הבית, לרבות, התביעה לתשלום דמי שימוש.

לאחר ששקלתי את מכלול ההכרעות בתיק זה והתנהלות הצדדים אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ח סיון תשע"ג, 06 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב